

1500613-36.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... diferentemente da quadrilha, a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas (e não quatro), agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 34 (tráfico de maquinário) desta Lei." (Nova Lei de Drogas Comentada, RT, p. 170, grifei).

Evidentemente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500613-36.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500613-36.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087916/2022 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 23975902 -

DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2087916 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIMAR DA CRUZ DO CARMO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

JANAÍNA DOS SANTOS TEIXEIRA, JOYCE GONÇALVES ALTEGIBES e JOSIMAR DA CRUZ DO CARMO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2.006, tudo em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal, conforme fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 135/137).

Oferecida a denúncia, esta foi recebida (fls. 138/139) e os requeridos citados.

Foram apresentadas respostas à acusação (fls. 153/157, 174/181 e 201/218, réus

Josimar, Joyce e Janaína, respectivamente). Em seguida, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e interrogados os requeridos.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há questão preliminar a ser apreciada.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados praticaram os crimes imputados na exordial acusatória.

A materialidade dos delitos restou demonstrada da mesma forma que ficou provada a autoria, em relação aos réus, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelas fotografias (fls. 62/68), pelo relatório final (fls. 98/104), pelo laudo toxicológico (fls. 145/147), que atesta resultado positivo para maconha e cocaína, bem como pela prova oral produzida.

De fato, o Policial Civil Júlio César Bassetti, quando inquirido em juízo, disse que é policial da DISE-Taboão da Serra e que trabalhavam em uma investigação em que efetuaram a prisão de 3 indivíduos, membros do PCC, responsáveis pela contabilidade e recolha do dinheiro do tráfico na região de Taboão, Itapecerica da Serra e Embu.

Aduziu que, após a prisão, foi dada continuidade à investigação referente à célula criminosa na região. Obtiveram informações sobre o abastecimento de drogas na região, o qual era realizado por duas mulheres, sendo uma delas de cabelo trançado na cor azul. Os indivíduos utilizariam um veículo Ford/Ka, cor branca, empregado como "uber" e viriam da região sul de São Paulo. Sem informação de placa do automóvel.

Explanou que fizeram campana na divisa de Embu com São Paulo, onde depois de algum tempo passou o veículo informado, com duas mulheres no banco de trás e uma delas com cabelo azul. Acompanharam o veículo e no momento oportuno realizaram a abordagem.

Com o motorista e com as duas mulheres nada de ilícito foi localizado. Contudo, ao revistar o porta malas, encontraram duas malas cheias de entorpecentes (15.000 porções de cocaína, com peso líquido de 10.185,2g; 2.800 porções de maconha, com peso líquido de 6.360,4g e 4.800 porções de crack, perfazendo o total de 1304,6g).

Pontuou que tinham informação que a droga vinha da região de Diadema, semanalmente. Inclusive, após a prisão das rés, foi efetuada nova prisão de outra pessoa fazendo o mesmo trabalho.

Esclareceu que as informações sobre o abastecimento e as características das mulheres foram obtidas nos documentos juntados na investigação objeto do inquérito em que foram feitas as primeiras prisões.

Relatou que até a prisão das rés havia informação de que somente as duas faziam esse trabalho, utilizando uber. Não havia revezamento de outras mulheres, bem como já tinham a informação com a características delas bem antes da campana de da prisão.

Disse que o motorista se assustou inicialmente, mas atendeu a ordem de parada do veículo. O veículo era utilizado pelo motorista como uber, mas no momento da abordagem o aplicativo não estava ligado.

Explicou, ao final, que a prisão posterior a relatada nestes autos foi realizada em um imóvel, um "barraco", no Jardim Montesano, em Itapecerica.

O Policial Civil Alan Fernandes Dias, também integrante da DISE-Taboão, quando ouvido em juízo, ratificou o depoimento de seu colega Júlio Cesar.

Acrescentou que a informação era de que o veículo Ford Ka era usado constantemente para buscar as drogas. Não tinha as características da outra mulher, somente a de cabelo azul. Afirmou que nenhuma das rés assumiu a propriedades das malas.

E as falas dos policiais e do delegado, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejada com os depoimentos prestados, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes" (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

"De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016" (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

"o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade" (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por

gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais" TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

A testemunha de defesa, Vera Lúcia Ferreira Mendes, disse em juízo que não conhece as rés, mas apenas o acusado Josimar, pois utilizou seus serviços como motorista particular em um período de dois meses, no ano de 2021, quando estava em tratamento de câncer. Pagava R\$ 350,00 mensais ao réu para leva-la ao trabalho, a semana inteira. Não utilizava o aplicativo. O réu nunca questionou o que ela levava na bolsa ou na mala.

A testemunha de defesa Janaina Samuel Soares, em juízo, disse que conhece a ré Janaina do salão de beleza, do qual é proprietária. A acusada Janaina trabalhava como diarista, fazendo faxinas e estava precisando de ajuda financeira, pois tinha que ajudar a família, inclusive a mãe. O marido da ré Janaina que conhecia seu irmão.

A acusada pediu uma chance no salão e resolveu testá-la, sendo que a ré acabou trabalhando no salão nos anos de 2019 e 2020 como caixa e recepcionista. A ré também fazia bico de faxina para complementar a renda.

Declarou que nunca teve reclamação ou desconfiança sobre a índole da ré Janaina. Ficou surpresa com a notícia da prisão.

A testemunha de defesa Daniela Carolina de Souza Vieira, quando inquirida em juízo, disse que conheceu a ré Joyce quando a acusada trabalhava vendendo salgados e fazia bicos como cuidadora de idosos. Nunca ouviu falar que a ré era envolvida com tráfico de drogas. Ficou surpresa com a prisão, pois ela parecia uma pessoa de boa índole, trabalhadora, uma ótima mãe e responsável com a família.

O réu JOSIMAR, quando interrogado em juízo, disse que tem 35 anos e não tem antecedentes criminais. Conheceu Joyce em razão dela utilizar seu serviço de motorista de aplicativo "99". Fez só a primeira corrida pelo aplicativo. Deixou um cartão com Joyce e os demais transportes foram realizados de forma particular, pois rende mais. Não conhecia Janaina até a data dos fatos.

Informou que no dia dos fatos Joyce ligou e agendou uma corrida para Diadema, onde buscaria mala com roupas para revender. Durante a corrida ela disse que ia pegar uma amiga que iria para o mesmo local.

Aduziu que se assustou com a abordagem do policial, mas parou imediatamente, pois estava trabalhando e não tinha nada a esconder.

Esclareceu que o carro pertence à senhora Mércia, que aluga o veículo por R\$ 350,00 por semana, sendo que tem locado o bem há um ano. Utiliza o automóvel para trabalhar como motorista doze horas por dia, de segunda a sábado. Algumas vezes folgava aos domingos.

A ré JOYCE, ao ser interrogada, disse tem 26 anos e é primária. Conheceu Josimar um dia antes, em uma corrida de aplicativo. Conhecia Janaina havia 04 meses aproximadamente.

Declarou que estava com Janaina em uma festa numa tabacaria quando um rapaz chamado "Gordinho" perguntou se ela queria fazer uns trabalhos para ele. Como estava precisando de dinheiro ela passou o telefone para referido indivíduo.

Algum tempo depois "Gordinho" ligou pela manhã e perguntou se ela queria buscar uma

mala de roupas na Cidade Ademar. Para tanto ele daria o dinheiro para pagar o uber e pagaria R\$ 200,00 pelo trabalho dela. Ressaltou que aceitou a proposta.

No mesmo dia, as 13h00min, tinha que pegar a mala. Então ligou para Josimar, que havia conhecido no dia anterior numa corrida de uber, e perguntou se ele podia levá-la. Em seguida combinaram a corrida.

Aduziu que ligou para Janaina, a qual informou que também iria pegar a mala no mesmo local, mas em outro horário. Então resolveram ir juntas para economizar no uber e ficar com mais dinheiro. Gordinho deu o dinheiro para ela pagar a viagem de ida e na volta ele pagaria o restante e o valor prometido.

Asseverou que seguiu com Janaina para o local. No recinto ligou para "Gordinho", que disse que alguém ia falar com ela. Em seguida apareceu um rapaz com uma mala e perguntou em qual carro ela estava. Referido indivíduo que colocou a mala no porta malas. Não avistou a mala direito, pois o rapaz colocou direto no porta-malas. Então, Janaina fez o mesmo procedimento, ocasião em que o rapaz entranhou e questionou se elas tinham ido juntas.

Informou que, no retorno, foram abordadas pela polícia, que apreendeu as malas com drogas e os levaram para delegacia. Não desconfiava que era droga, achou que era roupa porque Gordinho tem uma loja de roupas. Afirmou que ela era a pessoa com cabelo azul.

E a acusada JANAINA, ao ser interrogada em juízo, confessou que sabia que transportaria drogas, mas não sabia a quantidade.

Explanou que estava numa festa com Joyce, onde passaram o telefone para Gordinho, pois ele ofereceu um trabalho para ela.

No dia da prisão pela manhã ele ligou e perguntou se ela podia buscar uma mochila na Cidade Ademar por R\$ 200,00, sendo que ele pagaria o uber. Aceitou a proposta.

Logo em seguida Joyce a telefonou, dizendo que também iria buscar uma mochila e que tinha um conhecido que faria o uber. Então, decidiram ir juntas e dividir o dinheiro da outra corrida.

Esclareceu sabia que poderia ser drogas e que não sabia a quantidade, mas como precisava de dinheiro foi mesmo assim. Disse que Joyce e Josimar não sabiam do que se tratava.

Chegando ao local um rapaz apareceu com uma mala enorme, foi quando elas e Josimar se assustaram com o tamanho da mala. O indivíduo que entregou a mala questionou porque elas haviam ido juntas, se sabiam que não podiam ir juntas. Contudo, como já estavam lá, o rapaz colocou a mala no porta-malas meio desconfiado.

No caminho de volta foram abordados pela polícia, que encontrou as drogas e os levaram para delegacia.

Ressaltou que não conhecia Josimar antes da data dos fatos. Embora soubesse que poderia buscar drogas, acreditou que era pouca quantidade. Joyce e Josimar não sabiam o que estavam buscando e não conversaram sobre o assunto.

Pois bem.

Malgrado os acusados tenham tentado dirimir suas culpabilidades, apresentando, somente em juízo, suas versões, as provas produzidas vão em sentido contrário.

E, diante de todo o trazido nos autos, restou demonstrado que, de fato, os

requeridos praticaram o delito de tráfico de drogas, haja vista a quantidade da droga encontrada, seu modo de acondicionamento, bem o local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa.

Os depoimentos prestados pelos Policiais foram uníssonos e harmônicos ao descreverem, com riqueza de detalhes, as diligências realizadas durante o ocorrido.

Os agentes pontuaram realizavam investigação de célula do PCC e colheram informações acerca do transporte de drogas para outras localidades, notadamente que era realizado por duas mulheres, que constantemente se valiam de um veículo Ford/KA, de cor branca, para o transporte, sendo que o indivíduo que utilizava o automóvel também fazia o serviço de uber.

Tais fatos rechaçam por completo as narrativas dos acusados, uma vez que não é crível que todos estivessem no local dos fatos por mera coincidência e que nenhum deles, de fato, tinha conhecimento das drogas.

Evidente, pois, que os acusados estavam em conluio para a prática do tráfico de drogas, mormente porque a abordagem não decorreu de atividade isolada da polícia, mas sim de grande investigação que precedeu os fatos.

E não há qualquer razão para se acreditar em infundada incriminação por parte dos agentes da lei em desfavor dos réus.

Além disso, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a forma com que foram apreendidas, evidenciam que, de fato, os entorpecentes eram destinados ao abastecimento de biqueiras, notadamente porque o fato foi confirmado pelos policiais ouvidos.

Com efeito “os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Diante do exposto, está clara a prática, por parte de todos os réus, do que traz o tipo previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, na medida em que tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 15.000 porções de cocaína, com peso líquido de 10.185,2g; 2.800 porções de maconha, com peso líquido de 6.360,4g e 4.800 porções de crack, perfazendo o total de 1304,6g.

Como consequência, restou evidente a prática do delito previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal, na medida em que os réus tinham o mesmo objetivo, qual seja, a prática do tráfico, disposto na forma do artigo supra, o que pode ser sacado pelo modo em que a empreitada criminal era organizada.

Ademais, não é factível que eles tenham se unido para a prática de um único crime de tráfico e que a associação não era perene. Pelo contrário, conforme se verifica no depoimento dos agentes inquiridos, a atividade do abastecimento de drogas era realizada por duas mulheres e pelo veículo descrito nos autos, sendo que a atividade era duradoura.

A propósito, destaco que a doutrina classifica o crime de associação ao tráfico como sendo um crime de concurso necessário, que pressupõe, no mínimo, dois integrantes. Tal delito se distingue do concurso eventual de pessoas, que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinada conduta criminosa.

Não há se falar, no contexto dos autos, que tenha havido mero concurso ocasional, encontrando-se perfeitamente delineado, por conseguinte, o animus associativo indispensável para a tipificação do delito previsto pelo artigo 35 da Lei de Tóxicos. Discorrendo a respeito, Luiz Flávio Gomes preleciona com máxima clareza:

“O artigo 35 traz modalidade especial de quadrilha ou bando (art. 288 do CP). Contudo, diferentemente da quadrilha, a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas (e não quatro), agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 34 (tráfico de maquinário) desta Lei.” (Nova Lei de Drogas Comentada, RT, p. 170, grifei).

Evidentemente, provar o delito de associação para o tráfico não é uma tarefa fácil para o Estado. Afinal, em nosso sistema penal, ninguém pode ser condenado sem que haja prova da existência do crime.

Todavia, o Doutor Odilon de Oliveira, emérito Juiz Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, famoso por operar no combate ao crime organizado na região de fronteira daquele Estado com o Paraguai, discute, com sadias reservas, a questão da dificuldade para se conseguir prova quando o assunto é o tráfico de entorpecentes e a lavagem de dinheiro. Segundo ele, o Poder Judiciário não pode tornar-se insensível às dificuldades que a Polícia Federal encontra para conseguir provas em torno do tráfico e da lavagem.

Fundamenta o juiz: “Se a Justiça Federal, em qualquer de suas instâncias, se comportar com exagerada soberba em matéria de provas quanto ao tráfico de entorpecentes, deixando de compreender as dificuldades que o MPF e a Polícia Federal encontram para obtê-las, também pela natureza desse crime, complexidade das organizações e modus operandi, poucas vezes se conseguirá condenar peixes grandes.” (AÇÃO PENAL Nº 2000.60.02.002286-3 1ª VARA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL - Quinta Subseção - Ponta Porã - MS. Sentença datada de 23 de maio de 2005.)

Perfilhando do entendimento do citado magistrado, verifico que o mesmo raciocínio pode ser feito para o delito de associação para o tráfico.

E o conjunto probatório dos autos permite um decreto condenatório quanto ao referido crime. Avaliza esse entendimento o seguinte julgado:

Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 6656
Processo: 200071040036423 UF: RS Órgão Julgador: OITAVA TURMA
Data da decisão: 12/11/2001 Documento: TRF400082725
DJU DATA:16/01/2002 PÁGINA: 1396 DJU DATA:16/01/2002

“
.....

10. O juiz criminal não se pode permitir nenhuma ingenuidade no exercício de suas funções, especialmente quando trata do crime organizado de tráfico internacional de entorpecentes, que obviamente nunca é praticado por amadores, mas sim por delinqüentes de altíssima periculosidade, que sempre agem na clandestinidade e não hesitam, a qualquer preço, em usar toda sorte de artifícios para garantir a impunidade por seus atos nefandos.

11. A prova deve ser examinada no seu conjunto, dentro do contexto em que ocorreram os fatos, com os pés no chão e os olhos na realidade, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como elementos de convicção, ainda mais nos crimes, como o de associação para o tráfico, cometidos às escondidas, em que a prova direta é muito difícil senão quase impossível.

12. O silêncio do réu não implica confissão, mas é significativa a atitude de quem, preso e acusado injustamente de crime gravíssimo, prefere manter-se calado, pois a reação natural de qualquer pessoa inocente é proclamar veementemente a sua

inocência, esteja onde estiver”.

Assim, diante das provas que tais, não restam dúvidas de que o proceder dos acusados se amolda aos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Tóxicos, sendo suas condenações, quando aos delitos, medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam os crimes ou isentem os réus de pena.

Exaurida a instrução penal, superadas todas as questões trazidas à baila e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, CONDENO os réus JANAÍNA DOS SANTOS TEIXEIRA, JOYCE GONÇALVES ALTEGIBES e JOSIMAR DA CRUZ DO CARMO, qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, “caput” e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2.006, tudo em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, “caput”, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto aos réus.

Individualizar a pena é aplicá-la, no caso concreto, de acordo com a conduta praticada pelo réu. Por consequência, se o agente atinge o bem jurídico protegido de maneira mais gravosa, como ocorreu concretamente, a repressão deve ser maior.

Na primeira fase da dosagem, quanto ao tráfico, majoro as penas dos acusados em 1/6 (um sexto), pois há de se anotar que a conduta dos requeridos é mais reprovável do que a normal à espécie.

Com efeito, a expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas – 15.000 porções de cocaína, com peso líquido de 10.185,2g; 2.800 porções de maconha, com peso líquido de 6.360,4g e 4.800 porções de crack, perfazendo o total de 1304,6g –, seriam vendidas em porções fracionadas, de sorte que atingiriam muitas pessoas.

Assim, suas culpabilidades, diante disso, é mais acentuada.

Com efeito, tal entendimento foi confirmado no r. acórdão proferido nos autos de nº 0001381-11.2015.8.26.0360, com relação à sentença de lavra deste julgador:

“Em detida análise dos autos, de rigor o reconhecimento da pena-base acima do mínimo legal.

Ressalte-se que embora este Relator perfilhasse do entendimento que a quantidade da droga apreendida serviria para caracterizar o delito do tráfico de drogas, mas não era suficiente à exacerbação da pena-base, após minuciosa análise sobre o tema, filio-me ao entendimento de que a quantidade e natureza da droga, neste caso, recomendam a fixação acima do mínimo, o que é permitido pelo artigo 42, da Lei de Drogas.

O artigo 42, da Lei 11.343/06 prevê, de forma expressa, que na fixação das penas o Juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal: 'a quantidade da substância ou do produto', de modo que tal circunstância constitui elemento hábil a ser considerado para agravar a pena.

Sobre o tema a seguinte jurisprudência:

'A natureza e a quantidade da droga são fatores que, na fixação da pena-base no crime de tráfico, preponderam sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, e justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.' (STJ. HC 155.128/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2011, GJ 14/11/2011).

Porquanto, a quantidade de droga apreendida, frisa-se, justifica a exasperação da pena-base, assim como também entendeu o d. Magistrado a quo.” (TJSP - APELAÇÃO nº 0001381-11.2015.8.26.0360, 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, Rel. Paulo Rossi, julgado em 19/10/2016).

Ademais, as penas de todos os acusados, para ambos os crimes, também devem ser

exasperadas porque os réus traficavam e se associaram não para oferecer a droga aos usuários, mas sim para abastecer pontos de venda de drogas.

Evidente, pois, que suas condutas, nesse aspecto, são muito mais graves, motivo pelo qual aumento as penas dos réus em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, cabe ressaltar que a ré JANAINA não faz jus ao benefício trazido pela Súmula 545-STJ:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

É que o entendimento revelado nesta, por sua vez, deve estar em harmonia com o entendimento do STF:

“(...) A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal (...) STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013.”

A confissão da acusada foi parcial e qualificada. Logo, não é merecedora de tal benefício.

E, na terceira fase, não há nada a ser considerado.

Ressalto que os acusados não têm direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

Os réus transportavam expressiva quantidade de entorpecentes para o abastecimento de biqueiras, circunstâncias que indicam que estão efetivamente inseridos em atividade organizada.

Deveras, “porque diante da apreensão de considerável quantidade de drogas, inequivocamente destinadas ao comércio, admitindo-se a atividade ilícita, o delito cometido se afigura como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não há, ainda, “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no tráfico. Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles, ou não tivesse com eles algum vínculo”.

Isso demonstra que os acusados têm se dedicado a atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

“A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis

no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)". (TJ/SP; Ap. 0003339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, chego, pois, as seguintes penas para os réus:

Quanto ao crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para cada réu.

E quanto ao crime de associação para o tráfico, chego à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para cada acusado.

E, porque os delitos foram cometidos em concurso material, de rigor que suas penas sejam somadas, nos termos do artigo 69 do CP.

Dessa forma, chego à reprimenda total e definitiva de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.496 (um mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, para cada dos acusados.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada e diante dos veementes indicativos de que os réus estão incisivamente inseridos na traficância.

Nesse sentido, inclusive, se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que diante das particularidades do caso concreto e da apreensão de grande quantidade de drogas é possível afastar a figura do tráfico privilegiado e fixar regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas.

2. A Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes", circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico.

3. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n.

11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que "diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão." Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão do "sursis".

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária

reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Impossível a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Com efeito, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não garante que seja o real proprietário do bem, notadamente porque a propriedade de bem móvel se transfere com a mera tradição.

Nesse sentido:

“O fato de o veículo não possuir origem ilícita não impede, por si só, o perdimento, sobretudo quando utilizado para o sucesso da traficância, tal como se verificou no caso versando. Da mesma forma, o fato de encontrar-se em nome de outra pessoa também não obsta o perdimento, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade, como cediço, se consuma com a tradição, não exatamente com o registro no departamento de trânsito. Por corolário, emergindo dos autos elementos de convicção realçando ser o acusado o real proprietário do veículo em questão, utilizado na traficância abordada neste caderno, o perdimento se afigura inafastável, ressalvado, evidentemente, eventual direito da administradora do consórcio ou de terceiro de boa-fé, que não a esposa do aludido réu, evidentemente, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Penal.”

(STF, RExt com Ag 1.261.694/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/03/2020)

Ademais, o mero fato de o automóvel ter sido utilizado para a prática da empreitada criminosa é suficiente para que seja declarado perdido, não havendo, neste caso, que se arguir eventual direito de terceiro de boa-fé, pois ao se alugar o bem a alguém, o proprietário (se se considerar que pertence a terceiro) está passível de perder o automóvel caso ele seja empregado em atividade ilícita.

Somado a isso, inexistiu comprovação segura nos autos de que o automóvel, de fato, era alugado ao acusado e que a proprietária não tinha qualquer ciência do envolvimento do requerido com o tráfico de drogas.

Deveras, “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Diligencie a serventia para que o automóvel referido nos autos seja destinado às entidades ou órgãos competentes, oficiando-se.

Fica, portanto, definitivamente negados os pedidos de liberação do bem, feitos pela “terceira interessada”.

Coro corolário, fica indeferido o pedido de fls. 333/340.

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, pois presentes os fundamentos das prisões cautelares, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Ademais, ressalto que não é o caso de conceder a prisão domiciliar da ré que possui filho menor.

Não se desconhece do quanto disposto no artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. No entanto, a condição de ter filho menor de 12 anos não implica, necessariamente, à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Isso porque não há prova idônea de que a ré seja totalmente indispensável aos cuidados dos menores, notadamente ao se considerar que permaneceu presa durante toda a instrução do feito.

Ademais, o caso em tela é gravíssimo, já que envolve crimes que causam grande repercussão e desassossego social, além de existir provas de que a ré está inserida em atividades desenvolvidas por célula do PCC.

Sendo assim, presentes se encontram os requisitos da prisão cautelar como forma de

se garantir da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA